

1500009-44.2022.8.26.0412

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SENIVALDO DOS REIS JUNIOR

Comarca: Palestina

Foro: Foro de Palestina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALESTINA

Rua Capitão Faria, n. 1048, Fórum, Centro, Palestina, CEP 15470-000

Horário de atendimento ao público: das 12h30min às 19 horas

DATA: 12 de dezembro de 2022

LOCAL: Sala de Audiências

AUTOS Nº: 1500009-44.2022.8.26.0412

JUIZ DE DIREITO: Dr. Senivaldo dos Reis Junior

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Dr. André Luis de Souza (presente)

RÉU: FARLEN LUAN VIEIRA FALCHI (presente)

ADVOGADO: Dr. Cleber Uehara (presente)

TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO DIGITAL

Iniciados os trabalhos, a defesa requereu o prazo de cinco dias para juntada de substabelecimento, o que foi deferido pelo MM. Juiz

Após, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação Anderson da Silva Pina, Vinícius Franco Ferreira e Marcelo de Freitas Tessari (nesta ordem). Nas inquirições, as perguntas iniciaram pelo MM. Juiz com a expressa concordância das partes.

O Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha Jean Carlos Vieira, o que foi homologado Pelo MM. Juiz.

A seguir, o réu foi interrogado.

O registro das oitivas foi realizado mediante gravação digital (audiovisual), com a aquiescência das partes e testemunhas, conforme permissivo do artigo 405, § 1º, do CPP. Para maior fidelidade, os eventuais compromissos legais, as dispensas de compromisso e as contraditas foram registrados oralmente durante as oitivas.

Considerando tratar-se de processo digital, a mídia digital (DVD) com a gravação audiovisual que segue o presente termo.

Estando encerrada a instrução, pelas partes foi dito que não tinham diligências complementares a requerer.

Prosseguindo-se aos debates orais, foi dada a palavra às partes, tendo a MM. Juiz facultado às partes a apresentação de alegações em mídia digital, por resumo das teses ou oralmente (com gravação audiovisual).

O representante do Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais em mídia digital (audiovisual).

Na sequência, Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de FARLEN LUAN VIEIRA FALCHI, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 e art. 330 do CP c/c art. 69 do Código Penal, afirmando que no

dia 09 de outubro de 2021, por volta das 23h09min, na Avenida da Saudade, nº 1522, na cidade e comarca de Palestina/SP, o acusado vendia, oferecia, transportava, ou, trazia consigo droga, para fins de comércio ilícito, consistente em 07 (sete) invólucros de cocaína, pesando 18,280g (dezoito gramas e duzentos e oitenta miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no mesmo dia, horário e local narrados no parágrafo anterior, FARLEN LUAN VIEIRA FALCHI, já qualificado nos autos, desobedeceu a ordem de funcionário público.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado e outros dois indivíduos em atitude suspeita, na Avenida da Saudade, próximo ao Palestina Futebol Clube. Ao se aproximarem com a viatura, FARLEN saiu correndo e disse aos policiais que "não seria abordado". Os policiais deram ordem de parada, contudo, desobedecendo os militares, o denunciado continuou em fuga. No momento da fuga, FARLEN deixou sobre um muro, uma pochete que trazia consigo. Os policiais localizaram a pochete deixada pelo acusado e lograram êxito em abordá-lo. No interior da pochete, havia 07 (sete) invólucros plásticos contendo cocaína e a quantia de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais). O laudo pericial confirmou que a droga apreendida era cocaína. No aparelho celular apreendido com o acusado, verificou-se a existência de conversas que denotam a prática de tráfico de drogas. Restou apurado, contudo, que o investigado possuía o entorpecente quando foi abordado pelos policiais e que a sua intenção era de comercializá-lo, prática confirmada pelas conversas existentes no aparelho celular.

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), pelo laudo pericial (fls. 13/15) resultado positivo para a droga encontrada, bem como laudos periciais do telefone celular (fls. 49/66 e 229/247) e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, ANDERSON DA SILVA PINA, em solo policial disse: "Que o depoente no dia do fato estava na Petiscaria Avenida, nesta cidade, sentado em uma das mesas, quando em dado momento percebeu que uma viatura da polícia militar, encontrando-se os policiais Vinícius e Jean, abordaram dois indivíduos nas proximidades do salão do Palestina Futebol Clube. O depoente também notou que caminhava na companhia daqueles dois rapazes, porém um pouco na frente, o indivíduo de nome Falen, filho do Dirceu Falchi, informando ainda que devido a distância o depoente alega que não viu quem seriam os dois rapazes abordados pelos policiais. Que após a abordagem dos dois rapazes, Farlen continuou andando, mesmo sendo chamado pelos dois indivíduos que o acompanhavam, adentrando Farlen em seguida caminhando à Rua Stélio Machado Loureiro, atrás do Palestina Futebol Clube. Que após a abordagem dos dois indivíduos, os policiais militares seguiram com a viatura na direção de Farlen, parando em seguida a viatura na esquina, sendo que Farlen ao retornar pela mesma rua, veio de encontro a viatura e recebeu abordagem. O depoente

apenas presenciou o policial militar Vinícius com uma lanterna procurando algo nas proximidades da abordagem de Farlen e depois de certo tempo mostrou ao depoente, após chamá-lo e pedir para o depoente aproximar-se, uma bolsa que acredita ser tipo pochete, talvez de cor preta, pois não mais se recorda da cor, momento em que o policial Vinícius ao depoente "tá vendo aqui achei, mostrando em seguida uns pedaços de papel separados que o policial Vinícius disse que seria droga", alegando o depoente que não conhece droga, assim como não se recorda da quantidade que lhe foi mostrada por aquele policial militar, alegando por fim que após tais acontecimentos Farlen foi colocado na viatura e o depoente não sabe informar sobre o desfecho da ocorrência. Em juízo: "disse que estava no dia dos fatos no local, mas se recorda pouco, em razão de não ter dado muito atenção aos fatos; estava em uma pescaria do lado do Betão do açougue; esse local não tem costume de ficar aberto; mora próximo ao local dos fatos, mas não sabe aonde o Farlen mora; viu o Farlen descendo, mas não se recorda se estava com ele; quando o policial chegou estava sentado na mesa enquanto Farlen estava passando em frente, com outros amigos dele; quando o policial retornou chamou todo mundo quando se levantou da mesa; não chegou a ver se a ação foi somente em face do acusado; não viu o acusado vender drogas; viu a pochete depois mostrada pelo policial aonde o indicaram que era droga, mas não sabe por não ter contato com isso; não conseguiu ver a abordagem, visto que tinha um carro na frente.

A testemunha policial militar VINÍCIUS FRANCO FERREIRA, em solo policial disse o seguinte: "nesta noite estava de serviço com o Policial Militar Jean quando em dado momento ao realizarem patrulhamento de rotina pela vias públicas da cidade de Palestina/SP, depararam com três indivíduos em atitudes suspeitas, os quais encontravam-se conversando pela Avenida da Saudade. Que um dos indivíduos, conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, em razão de denúncias, de nome Farlen Luan Vieira Falchi, antes de ser abordado disse que "não seria abordado", saindo correndo, oportunidade em que lhe foi dado voz de parada, não sendo obedecida, contudo após perseguição por parte do depoente e seu colega de serviço, a princípio notaram que Farlen deixou alguma coisa que trazia consigo sobre um muro, sendo que após êxito na abordagem policial, mesmo diante da resistência daquele indivíduo, foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo e algemá-lo. Notando então que o mesmo estava sem a pochete, vieram a perceber que a mesma havia sido deixado momentos antes por Farlen sobre um muro. Neste momento solicitaram que a testemunha Anderson que estava nas proximidades acompanhasse a abordagem policial, sendo que após a localização da pochete, restou encontrada em seu interior sete (07) invólucros plásticos de cor branca contendo substância petrificada na cor branca, sendo dois dos invólucros na cor amarela também com substância petrificada, assim como a quantia de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro e um aparelho celular LG K8. Indagado sobre a procedência da droga, Farlen disse que trava-se de "cocaína", alegando apenas que a teria adquirido na cidade de São José do Rio Preto/SP, não fornecendo maiores informações. Diante de tal situação apresentaram Farlen neste plantão policial com os demais objetos encontrados em seu poder para as providências cabíveis pela autoridade policial plantonista. Deixa consignado que a testemunha Anderson não acompanhou a viatura até este plantão, contudo prestou sua versão em campo próprio em ocorrência elaborada pela corporação da polícia militar". Em juízo ratificou a sua versão.

A testemunha, policial militar, JEAN CARLOS VIEIRA, em solo policial assim aduziu: "o depoente na condição de policial militar lotado no Pelotão PM de Palestina/SP, informa que nesta noite estava de serviço com o policial Vinícius sendo que ao realizarem patrulhamento pela vias públicas da cidade de Palestina/SP, em dado momento depararam com três indivíduos em atitudes suspeitas, os quais encontravam-se conversando pela Avenida da Saudade. Informa que um dos indivíduos, conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, em razão de denúncias, declinando seu nome como sendo Farlen Luan Vieira Falchi, antes de ser abordado disse que "não seria abordado", saindo em seguida correndo, oportunidade em que lhe foi dado voz de parada, não sendo obedecida, contudo após perseguição, a princípio notaram que Farlen deixou alguma coisa que trazia consigo sobre um muro, sendo que

após êxito na abordagem policial, mesmo diante da resistência daquele indivíduo, foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo e algemá-lo. Que ao notarem que Farlen estava sem a pochete, vieram a perceber que a pochete havia sido deixado por Farlen momentos antes sobre um muro. Esclarece que solicitaram então que a testemunha Anderson que estava nas proximidades os acompanhasse na abordagem policial, sendo que após a localização da pochete, encontrou-se em seu interior sete (07) invólucros plásticos de cor branca contendo substância petrificada na cor branca, sendo dois dos invólucros plásticos na cor amarela, assim como a quantia de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro e um aparelho celular LG K8. Farlen ao ser indagado sobre a procedência da droga, disse que trava-se de "cocaína", alegando apenas que a teria adquirido na cidade de São José do Rio Preto/SP, não fornecendo maiores informações. Diante de tal situação apresentaram Farlen neste plantão policial com os demais objetos encontrados em seu poder para as providências cabíveis pela autoridade policial plantonista. Deixa consignado que a testemunha Anderson não acompanhou a viatura até este plantão, contudo prestou sua versão em campo próprio em ocorrência elaborada pela corporação da polícia militar". Em juízo teve sua participação dispensada.

A testemunha, MARCELO FREITAS TESSARI, em juízo disse o seguinte: "reporta-se ao seu relatório de investigação, sendo que os policiais tinham flagrado o acusado Farlen com invólucros de cocaína; em janeiro de 2022 estava elaborando um Boletim de Ocorrência por ameaça e a vítima pediu autorização para usar o whatsapp web e as ameaças tinham sido de um "Vitininho Jogador", e por livre espontânea a vítima começou a colaborar com a investigação, sendo que foi informando os traficantes da cidade; nessa ocasião o nome do acusado foi citado como um dos principais traficantes; no dia que foi pego pela polícia o acusado teve apreendido o seu celular e encaminhou-se para a política técnica, conforme foi feita a extração foi possível pegar várias mensagens de whatsapp com negócios de compra de drogas por parte do acusado; foram várias situações que a investigação conseguiu levantar que o acusado estava envolvido por tráfico de entorpecentes; o acusado disse que a amiga teria chegado nele falando por gírias e perguntando a ele se teria drogas para vender; foram feitos 3 flagrantes em face do acusado, sendo que no último encontraram mais drogas na casa dele; na ocasião viu o conteúdo das conversas, lembrando-se que tinha várias conversas sobre venda de drogas."

FARLEN LUAN VIEIRA FALCHI, em seu interrogatório disse o seguinte: "no dia dos fatos estava descendo a avenida indo para a casa de uma amiga sua; descendo encontrou os policiais, os viu de longe; os policiais pediram para ele parar e ele parou, sendo que nenhum momento desobedeceu a ordem de parada; tinha 7 pinos de cocaína no seu bolso, lhe apresentaram no plantão, sendo que é usuário; era final de semana e teria uma festa para curtir; a quantidade era para uso, sendo que nem era muito; é conhecido nos meios policiais por ser uma cidade grande; é tão somente "laranja" por ser usuário; não tem condições de ser traficante porque a polícia não encontra os grandes traficantes; a conversa com Jéssica é conversa de usuários, sendo que "óleo" tinha bastante para vender; nunca encontraram óleo com ele para ser apreendido; sobre as conversas disse que se refere a comprar drogas e não para vender; sendo que desconhece

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente

informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu defensor, tiveram estas plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.

STJ, HC 115516/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 03/02/2009.

"O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova".

STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJE 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso.

TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 20.08.2013.

"No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais militares, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional.

Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreiamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante".

TJSP, Apelação n. 0068618-51.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2018.

Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico, além do passado do réu ligado à criminalidade indicam que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.

No mais, as conversas apresentadas no Laudo Pericial às fls. 229/247 são precisas

que indicam que o réu é traficante, e, portanto, vendia drogas, bem como trazia consigo cocaína. Veja-se que as conversas trazem pessoas perguntando ao acusado a respeito de possibilidade de ter “bala”; “pó”, entre outros. Inclusive há conversa com “QBD” prefixo de quebrada, o qual o fornecia drogas, conforme print acostado aos autos.

Veja-se que mais precisamente às fls.236 o acusado mesmo aduz que “eu to tenho tudo maconha pó e óleo tbm”, de forma a indicar que vendia drogas a outras pessoas.

Anoto também que o acusado disse em prints de fls. 237 o seguinte: “Boa- Qbd ai e o doce?”, de forma clara a indicar sobre a sua traficância.

Note-se que firmeza e segurança da prova colhida que o acusado vendia droga como espécie de delivery, visto que faziam o pedido em seu celular e ele tinha a incumbência de levar as drogas ao usuário.

Quanto ao delito de desobediência, veja-se que o acusado se recusou a parar após ordem emanada dos policiais, sendo que somente foi detido, sendo necessário o uso de força moderada para sua apreensão. As falas dos policiais foram firmes e seguras, de modo a demonstrar a caracterização do delito.

Assim, resta patente o crime de desobediência, porquanto se recusou o acusado a obedecer a ordem de parada dos milicianos, dando ensejo a uma perseguição.

Sobre a tipicidade da conduta, convém trazer à baila recente julgado do STJ que uniformizou a jurisprudência sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPLICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância.

2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.

3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

No presente caso, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330 do CP.

No mais, não convence a argumentação do acusado dos valores encontrados com si, visto que nada trouxe a comprovar que seria proveniente de algum tipo de trabalho lícito, sendo que caberia a si o ônus dessa prova, em razão de ter alegado, conforme predisposto no art. 156 do CPP.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de “reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”, bem como o delito do art. 330 do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas. Aliás, foi imbuído desse espírito que o STJ sumulou o enunciado 443 para a terceira fase da dosimetria.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Portanto, em referência ao critério da natureza da droga, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merecem valoração nesta fase a maconha e cocaína, sendo que esta em especial (e em maior grau o crack, seu derivado), por causar severa dependência em seus usuários. Entendo que a cocaína tem alto teor alucinógeno, o que faz aumentar a pena-base do delito.

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado com antecedentes criminais, visto que possui condenação posterior, o que inviabiliza a reincidência, mas pode ser aplicada nesta etapa; c) Conduta social: a vida do acusado é para o cometimento de delitos, visto que conhecido nos meios policiais e com diversas passagens, o que faz tal circunstância ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: são normais à espécie; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão. h) Comportamento da vítima: não há motivos para serem consideradas negativas ou positivas.

Portanto, entendo que a pena-base deve ser aumentada em 2/5 da pena-base para o delito de tráfico de entorpecentes.

Fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Para o delito de desobediência aumento a pena em $\frac{1}{4}$, fixando-a em 18 dias e 12 dias-multa.

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

A confissão relativa ao uso da droga não enseja a incidência da atenuante quando da condenação por tráfico:

No que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, observa-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, e não merece reparo.

O benefício foi negado ao paciente por ter ele assumido, tão somente, a posse da droga para consumo próprio, e não propriamente o tráfico de entorpecente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a confissão espontânea do agente, sentenciado por tráfico de entorpecentes, de ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

A propósito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NEGOU A PRÁTICA DO DELITO, ALEGANDO SER MERO USUÁRIO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu admita a prática do crime que lhe é imputado, contribuindo, assim, com o deslinde da persecução criminal. Na espécie, o Tribunal de origem destacou que o paciente negou a prática delitiva em juízo, alegando que teria comprado o entorpecente apenas para consumo e não para a mercancia, razão pela qual não deve incidir, na espécie, a referida atenuante. 2. Ante o não acolhimento do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, resta prejudicado o pleito de compensação da agravante da reincidência com a referida atenuante. 3. Habeas corpus não conhecido."

HC 373.054/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 4/5/2017.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AFASTADA. TRANSPORTADOR DE DROGAS. MULA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 65, III, 'D', DO CÓDIGO PENAL - CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE QUE NÃO SE APLICA PARA CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS QUE RECONHECE APENAS O USO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de prova, que a ré, presa enquanto praticava o transporte internacional de drogas, integrava organização criminosa, sendo inviável afastar tal constatação, em razão do vedado revolvimento fático-probatório, conforme Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A confissão espontânea pela prática de uso de drogas não enseja a aplicação da referida atenuante se o réu foi condenado por tráfico de drogas, conforme jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido."

AgRg no AgRg no AREsp 1.053.604/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1/6/2017, DJe 9/6/2017.

STJ, HC 431541/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Incabível o redutor. Como se sabe, o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial sob o uso ilegítimo da força; as organizações criminosas instituem, em um sistema de regras paralelo ao direito estatal, formas de domínio sobre os pontos conhecidos de venda de drogas, falando-se inclusive em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância nestes locais indica inserção do agente nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada.

No mais o acusado possui antecedentes específicos, o que impede o reconhecimento da atenuante legal.

Torno a pena definitivizada do delito de tráfico em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa e ao delito de desobediência em 18 dias e 12 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrario sensu" das alíneas "b" e "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o fechado. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial fechado. A reincidência também impede a aplicação do redutor, a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR, FARLEN LUAN VIEIRA FALCHI, à pena de reclusão, pelo prazo de 7 (sete) anos, em regime inicial fechado, bem como a 700 (setecentos) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como a detenção de 18 (dezoito) dias e multa em 12 (doze) dias-multa em razão do delito do art. 330 do Código Penal, observando-se na execução criminal o teor do art. 76 do Código Penal.

Inviável a possibilidade de recurso em liberdade, em razão de estar o acusado segregado por outro processo.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Sentença publicada em audiências. Saem os presentes intimados.

Então as partes foram consultadas quanto ao interesse em recorrer, conforme manifestações lançadas ao final da sentença. O Ministério Público informou não ter interesse em recorrer, contudo a defesa informou ter interesse em recorrer.

Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pelo réu e pela sua defesa técnica. Dê-se vista à defesa para apresentação das suas razões de apelação. Depois, dê-se vista ao Ministério Público para contrariedade. Depois de apresentadas as razões e as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do apelo, com as homenagens deste juízo. Ficam as partes intimadas".

Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Termo digitado e lavrado por mim, ____ (Antonio Silvio Volpe Sagliocco, Matrícula 94.430-4), Organizador das Audiências. Termo digitalmente assinado pelo magistrado.